

1500327-23.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... O Boquita era o Thiago Willie, condenado por tráfico anteriormente. O irmão do Boquita é o Tiago. A casa era do Reinaldo e eles negaram a traficância, dizendo que eram apenas usuários. Nenhum deles aparentava que estava sob efeito de substância ou portava objetos para uso de drogas. Não conhecia os réus, exceto o Reinaldo que era conhecido por tráfico de drogas. Acha que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500327-23.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-23.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130148/2022 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 24944649 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2130148 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2130148 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de João Cláudio dos Santos Silva, Thiago Ribeiro dos Santos e Reinaldo Cortez Rufino, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 13 de maio 2022, por volta das 01h20, na Rua das Mangueiras, bloco 01, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, divisão de atos executórios e com unidade de desígnios,

vendiam, traziam com eles e guardavam 77 (setenta e sete) porções de crack, subproduto da cocaína, pesando aproximadamente 16,75 gramas, 41 (quarenta e um) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 63,71 gramas, e 02 (duas) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 4,88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Prisão em flagrante dos réus convertida em preventiva na decisão de págs. 100/111.

A denúncia de págs. 97/99 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/67.

O réu João Cláudio dos Santos Silva foi notificado (pág. 165) e apresentou defesa prévia (págs. 182/183), alegando ser apenas usuário de entorpecentes.

Os réus Reinaldo Cortez Rufino e Thiago Ribeiro dos Santos foram notificados (págs. 161/163) e apresentaram defesa prévia (págs. 216/230), sob a alegação de que os réus estão sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão que converteu a prisão e flagrante em prisão preventiva.

Pela r. Decisão de pgs. 211/215 foi indeferida a liminar em habeas corpus impetrado em favor do réu-paciente João Cláudio dos Santos Silva.

A denúncia foi recebida aos 14 de julho de 2022, designando-se audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 2022. Foi mantida a prisão preventiva na decisão de lavra do MM. Juiz Substituto José Oliveira Sobral Neto (págs. 235/239).

Laudos periciais acrescentados ao acervo probatório nas pgs. 253/261.

Foi instalada audiência de instrução no dia 03 de agosto de 2022 que porém não se realizou por problemas técnicos de conexão com o CDP - pgs. 311/312.

Pela decisão de pgs. 313/314 a prisão cautelar foi substituída por medidas diversas em meio aberto.

Audiência de instrução redesignada para 04 de outubro de 2022 - pgs. 351/352.

A solenidade foi finalmente realizada, conforme termo de pgs. 489/490 e mídia audiovisual encartada no SAJ - pgs. 487/488.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois conforme a síntese da prova oral apresentada concluiu que as versões dos policiais são coerentes e harmônicas, diferentemente do interrogatório dos réus de onde extraiu inconsistências. Requer o aumento da pena base diante da variedade de drogas. Reinaldo é confesso e faz jus a atenuante, embora ostente maus antecedentes e não faça jus ao privilégio. Não se opõe ao benefício em relação a João Cláudio e Thiago que podem receber regime aberto, enquanto Reinaldo deve suportar regime fechado - pgs. 528/532.

A defesa, por sua vez, manifestou-se a favor de João Cláudio dos Santos Silva nas pgs. 536/538 alegando que nenhuma droga foi apreendida com o réu, tampouco houve abordagem de qualquer indivíduo que tenha adquirido drogas do réu. Indica a inexistência de provas de qualquer campana policial, tampouco documentos fotográficos ou depoimentos de pessoas abordadas. O réu sequer é conhecido dos meios policiais. Aponta que o procedimento policial "na verdade sempre facilita seu serviço e dificulta a instrução no ponto de vista do acusado, pois o acusado na

data dos fatos estava sozinho, não havendo possibilidade de arrolar testemunhas em sua defesa, o que por vezes, muito embora não há entendimento que os policiais tenham interesse em prejudicar um inocente atribuindo ao acusado um fato criminoso, por vezes esses mesmos policiais podem interpretar a conduta do acusado por ocasião da compra do entorpecente para seu uso pessoal de forma equivocada e/ou especulativa em relação a traficância." Roga por criteriosa análise deste Juízo reconhecendo-se a necessidade de aplicação do benefício da dúvida, diante da insuficiência probatória. Requer a absolvição na forma do inciso VII do art. 386 do CPP.

A defesa de Reinaldo Cortez Rufino e Thiago Ribeiro dos Santos, em derradeiras alegações, argumenta que tendo os fatos ocorrido à 01:20 da madrugada nos predinhos do "Profast", local que é de péssima iluminação, soa pouco crível a versão dos policiais de que puderam ver a traficância narrada. Argumentam que a droga estava dentro de uma residência que foi invadida pelos policiais sem consentimento e sem mandado. Reputa isolada a palavra dos policiais que teriam ingressado ilegalmente dentro da residência do acusado Reinaldo. Requer seja considerado ilícito o ingresso domiciliar e caso não seja este o entendimento, pugna no sentido de que a palavra dos policiais não seja considerada suficiente. Alternativamente, requer o benefício do § 4º do art. 33 do Código Penal, argumentando que a condenação de Reinaldo é antiga e não deve ser considerada como Maus Antecedentes eternamente. Sendo reconhecido o regime aberto, requer o direito de apelo em liberdade - pgs. 539/546.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 22/23), auto de constatação preliminar (págs. 24/29), além dos laudos periciais (págs. 253/255, 256/258, 259/261), que indica que a massa líquida da substância foi de 5,06 + 12,5 + 21,1 gramas, totalizando 38,66 gramas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Júlio César de Araújo Zocal, em solo policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito esclareceu que "na data de hoje, ciente do intenso tráfico de drogas que ocorre nos predinhos conhecidos como "Profast", posicionaram em local estratégico e passaram a observar 03 (três) indivíduos, posteriormente identificados por Thiago Ribeiro dos Santos, João Cláudio dos Santos Silva e

Reinaldo Cortez Rufino. Após observar por diversas vezes os indivíduos João Claudio e Thiago "servindo" diversos usuários que ali se aproximavam, sendo que entregavam algo e recebiam o dinheiro do usuário, atitude esta típica do tráfico ilícito de entorpecentes, resolveram intervir. Após realizada a venda, estes 02 (dois) indivíduos iam até o terceiro indivíduo, Reinaldo, que ficava na parte de baixo de uma escada próxima a eles, entregavam o dinheiro e recebiam mais drogas, que também ficava escondida na parte de baixo desta escada. Em seguida, foi realizada a abordagem dos 03 (três) indivíduos, sendo localizado com Thiago 05 (cinco) pedras de uma substância análoga a crack e 03 (três) eppendorfs de uma substância análoga a cocaína. Com João Claudio foi localizado R\$30,00 (trinta reais) em notas diversas. Com Reinaldo, nada de ilícito foi encontrado, porém próximo a referida escada onde ele ficava "abastecendo" os outros dois indivíduos, foram localizadas uma sacola com 72 (setenta e duas) pedras de uma substância análoga ao crack e 38 (trinta e oito) eppendorfs de uma substância análoga a cocaína, bem como R\$78,00 (setenta e oito reais) em notas fracionadas. Desta feita, foi proferida voz de prisão em flagrante aos três indivíduos pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e encaminhados até este plantão policial, sendo esta ratificada pela autoridade policial de plantão." - p. 02.

Em juízo, ratificou em sua substância a versão apresentada em estado de flagrância, salientando que estava de serviço com o soldado Roberto e como era de conhecimento da equipe o intenso tráfico de drogas na região dos predinhos do Cassucci conseguiram se aproximar do local onde é feito o comércio de drogas e observaram a movimentação de vários indivíduos que ali estavam. Viram 3 indivíduos e 2 deles fazia contato com usuários de drogas, pegava dinheiro e entregava droga. Eles iam até um portãozinho de madeira que fica na lateral de um dos prédios onde eles estavam e ali estava o 3º indivíduo, Reinaldo Rufino, que entregava a droga. Ele guardava a droga e o dinheiro e os outros dois entregavam as drogas. Fizeram a abordagem do Tiago e do outro e Reinaldo também. Com um deles havia 5 pedras de crack e 3 pinos de cocaína e com o outro havia dinheiro. Com Reinaldo nada foi encontrado, mas nas buscas no local onde estava viram várias plantas e localizaram um sacola com grande quantidade de pedras de crack e pinos de cocaína, além de dinheiro e maconha. Não se recorda a quantidade exata, mas eram idênticas às porções que os outros indivíduos portavam. Caíram em contradição dizendo que estava de passagem e o outro disse que era apenas usuário de drogas. Antes da abordagem viram 3 a 4 vendas. Há muitos indivíduos que param ali, teve momento que havia 3 veículos parados ao mesmo tempo no local. A observação foi feita nas proximidades da escola Caic de 15 a 20 metros. Os 3 já tinham sido abordados pelo depoente. Sempre perambulando naqueles locais. O Reinaldo Rufino mora no prédio onde foi abordado. O Thiago não sabe o João Cláudio mora próximo também. O João Cláudio é irmão do "boquita" e havia informações de que ele estava gerenciando o tráfico no local. Na época da prisão do "Boquita" não se lembra do envolvimento do João Cláudio com o grupo. Havia R\$ 30,00 em dinheiro com o João Cláudio em notas fracionadas. O local é escuro, porém no dia dos fatos havia iluminação dos próprios prédios que facilitou a identificação dos indivíduos. Mas, ali geralmente é bem escura a rua. O prédio de Reinaldo estava apagado e os dois laterais estavam acesos. A sacola de droga estava entre vasos de plantas, antes da entrada da residência. Havia um portão de madeira por onde ele entregava a droga para os outros dois indivíduos. O portão estava fechado durante a campana, mas no momento da abordagem o Rufino deixou aberto. Não entraram na casa do Reinaldo. O local é de acesso comunitário, área comum de outros prédios. Não era parte da casa dele. Não adentrou na casa dele. Não se recorda se nenhum deles portava bebida.

Marcos Roberto do Prado, em solo policial, prestou depoimento semelhante ao parceiro de farda anteriormente ouvido. Vale transcrever: "que na data de hoje, ciente do intenso tráfico de drogas que ocorre nos predinhos conhecidos como "Profast", posicionaram em local estratégico e passaram a observar 03 (três) indivíduos, posteriormente identificados por Thiago Ribeiro dos Santos, João Claudio dos Santos Silva e Reinaldo Cortez Rufino. Após observar por diversas vezes

os indivíduos João Claudio e Thiago "servindo" diversos usuários que ali se aproximavam, sendo que entregavam algo e recebiam o dinheiro do usuário, atitude esta típica do tráfico ilícito de entorpecentes. Após realizada a venda, estes 02 (dois) indivíduos iam até o terceiro indivíduo, Reinaldo, que ficava na parte de baixo de uma escada próxima a eles, entregavam o dinheiro e recebiam mais drogas, que também ficava escondida na parte de baixo desta escada. Em seguida, foi realizada a abordagem dos 03 (três) indivíduos, sendo localizado com Thiago 05 (cinco) pedras de uma substância análoga a crack e 03 (três) eppendorfs de uma substância análoga a cocaína. Com João Cláudio foi localizado R\$30,00 (trinta reais) em notas diversas. Com Reinaldo, nada de ilícito foi encontrado, porém próximo a referida escada onde ele ficava "abastecendo" os outros dois indivíduos, foram localizadas uma sacola com 72 (setenta e duas) pedras de uma substância análoga ao crack e 38 (trinta e oito) eppendorfs de uma substância análoga a cocaína, bem como R\$78,00 (setenta e oito reais) em notas fracionadas." (pgs. 03).

Na audiência de instrução, o mesmo policial militar asseverou que tinha recebido denúncia de que a residência daquele local era palco de tráfico intenso de drogas e que Reinaldo armazenava a droga debaixo da escada. Conseguiram observar a traficância e os dois outros indivíduos faziam contato com usuários, pegavam a droga com Reinaldo e voltava para entregar. Depois de várias vendas conseguiram fazer a abordagem. Os dois elementos estavam na porta da residência e tinha droga com eles. O Reinaldo estava debaixo da escada e nela encontraram vários entorpecentes semelhantes àqueles apreendidos com os dois. Um dos indivíduos era irmão do "Boquita". Não conhecia ele, mas ele confirmou que era irmão do Boquita. O Boquita era o Thiago Willie, condenado por tráfico anteriormente. O irmão do Boquita é o Tiago. A casa era do Reinaldo e eles negaram a traficância, dizendo que eram apenas usuários. Nenhum deles aparentava que estava sob efeito de substância ou portava objetos para uso de drogas. Não conhecia os réus, exceto o Reinaldo que era conhecido por tráfico de drogas. Acha que foi preso por 155 e também por tráfico anteriormente. Reinaldo ficava debaixo da escada, com a sacola. Salvo engano, com os outros dois elementos foram apreendidos entorpecentes. Não se lembra se havia entorpecente. A droga encontrada com os acusados era a mesma, semelhante àquela encontrada com o Reinaldo. Foi localizada uma quantia alta de dinheiro, em notas diversas. Nunca abordou o Tiago em outra ocasião. Conhecia o Reinaldo por causa dos "predinhos", fez várias abordagens com ele ali e nada foi localizado, mas ele já era conhecido dos meios. A rua é iluminada, porém o fundo dos prédios não. O local era de perfeita observação porque eles saiam do local e iam até o carro, onde podiam ser vistos. Estavam a uma distância de 15 a 20 metros durante as observações. Não adentraram no predinho de Reinaldo. As drogas estavam debaixo da escada e para entrar lá existe portão, mas estava quebrado, estava totalmente aberto ali. Não se recorda se havia pinga no momento da abordagem.

Maria Aparecida Ribeiro é tia do Thiago. Não viu nada. O Thiago mora em São Paulo, mas na época ele estava morando com a depoente. Não conhece os outros dois. O Thiago trabalhava na roça. Ele tinha R\$ 30,00 com ele. O pai dele deu para ele tomar um lanche. Ele trabalhava das 05:30 até as 17:00 de segunda a sexta-feira. Ele recebia R\$ 400,00 por semana. Ele ajudava com R\$ 150,00 por semana. O réu mora em São Paulo com os pais. Ele está trabalhando num mercado com o irmão dele. Nunca houve movimentação de pessoas procurando o Tiago na casa da depoente. Ele nem fumava em casa. Não sabe o que os vizinhos disseram sobre a droga. A depoente mora no bairro Chico Xavier na rua Zilda Gama, 123. Fica um bairro de distância da rua das Mangueiras. Dá uns 20 minutos de caminhada até a rua das Mangueiras. Não conhece Reinaldo.

O réu Reinaldo Cortez Rufino, exerceu seu direito de permanecer em silêncio perante a Autoridade Policial - pg. 07.

Em Juízo, o réu declarou que tem 44 anos. Estudou até a primeira série apenas. Foi preso por artigo 155. Usou crack e maconha. Antes de ir preso estava usando, agora

não usa mais. Nunca foi preso. É solteiro e mora com sua mãe. O que os policiais falaram é mentira. Havia dois moleques passando e eles sentaram na porta e a polícia abordou eles. O depoente apavorou e entrou para dentro de casa. Os policiais abriram o portão, a maçaneta da porta e perguntaram o que era isso. Perguntaram se era do depoente e o depoente assumiu. Eles também acharam uma sacolinha com "pó" e "maconha". Aí o Zocal perguntou se tinha mais droga. O depoente falou que não tinha mais. Falou que a droga que tinha era só aquela. Confessa que a droga era tudo sua. Estava desempregado e comprou para vender. Mas, no dia não chegou a vender porque a polícia chegou antes e abordou os moleques (João Cláudio e Thiago). Não conhece os demais réus. Não chegou a beber pinga com eles. Eles estavam apenas passando na rua e viu a polícia abordando eles. A polícia viu que o depoente apavorou, entrou e fechou a porta e achou o potinho com pedras. Depois eles entraram e acharam mais drogas. Os R\$ 78,00 lhe pertenciam, mas não tinha vendido nenhuma droga ainda. Tinha acabado de pegar as drogas para vender. Estava pegando sucata na época. Atualmente está trabalhando com seu cunhado como gesseiro. Nunca foi processado por tráfico. A iluminação lá no local estava escuro. A rua tem iluminação.

O réu Thiago Ribeiro dos Santos, igualmente permaneceu em silêncio na delegacia de polícia - pgs. 08.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, alegou que nunca foi preso ou processado. Vai fazer 22 anos. Trabalha num mercado de seu irmão. Estudou até a sétima série. Ouviu o que os policiais disseram e disse que tinha recebido R\$ 30,00 do seu pai pelo Pix. Foi na casa da sua namorada e então encontrou o João Cláudio. Gastou o dinheiro. Não foi apreendido dinheiro com o depoente, nem droga. Viu quando a polícia achou a droga que estava no quintal do Reinaldo. Não conversou com o Reinaldo, nem manteve contato com ele. Estava ali há uns 5 a 10 minutos. Reinaldo estava na casa dele e tinha dado um pouco de bebida para o depoente e o João Cláudio. Sua namorada não estava junto nessa hora. Quando a polícia encontrou a droga no quintal o Reinaldo assumiu. Conhece o João Cláudio da pracinha onde ficavam bebendo, perto da casa dele. O João Cláudio na época morava perto da rua das Mangueiras. Agora ele se mudou. Confirma que estava de frente ao prédio do Reinaldo, mas não viu Reinaldo entregando droga para ninguém. Tinha bebido com o João Cláudio e depois o Reinaldo saiu ali e ofereceu bebida. Não conhecia o Reinaldo e não sabe se João Cláudio conhecia, mas mesmo assim ele saiu ali e ofereceu bebida. O dinheiro do Pix tinha gastado comendo lanche. Seu pai lhe mandou na conta. Não sacou o dinheiro, apenas passou o cartão. Estava morando em São José há 3 meses. Trabalhava e morava com sua tia. Os policiais entraram na casa do Reinaldo e encontraram mais "coisas". A iluminação do local estava meio escuro. Os policiais não disseram que iam liberar o depoente. Eles falaram para o Reinaldo "segurar" as drogas dele e ameaçaram de "zoar" a mãezinha dele que estava dormindo lá. Eles disseram que iam liberar o depoente.

O réu João Cláudio dos Santos Silva, a exemplo dos demais envolvidos, preferiu deixar a versão policial isolada durante a fase inquisitiva, conforme se verifica nas pgs. 09 em que exerceu o direito ao silêncio.

Durante seu interrogatório, em juízo, João Cláudio declarou que nunca foi preso, nem processado. Trabalha de fim de semana. Usava cocaína, agora não usa mais. Nunca foi internado. É solteiro. Não tem filhos. Mora com sua mãe, pai e irmã. Estudou até a sétima série. Ouviu o que os policiais disseram. Estava apenas passando na rua e parou lá para beber e encontrou o Tiago. Chamou ele para beber com o depoente. Estavam bebendo e foram abordados pela viatura. Nisso o Reinaldo saiu lá fora e também foi abordado. Viu a polícia achando drogas na casa do Reinaldo e então os policiais mandaram o depoente e o Thiago entrar na casa também. Foi encontrado dinheiro também. O dinheiro era do Reinaldo. Com o depoente não tinha dinheiro. Tinha apenas a bebida que comprou. Comprou a bebida no barzinho da rua debaixo da escola e pagou R\$ 5,00. Era pinga. Conhece o Thiago porque ele estava

morando perto da casa do depoente fazia uns 3 meses. O Reinaldo só conhecia de vista. Ele mora perto dos predinhos também. Não sabe dizer o porquê os policiais estão dizendo que o depoente pegava droga e entregava para os outros. Eles iam liberar o depoente e o Thiago, devolveram o celular deles. Mas, quando acharam a droga com o Reinaldo não quiseram mais liberar. Atualmente mora na vila Pereira, mas na época morava no Eduardo Cassuccci que dá uns 25 minutos de caminhada até os predinhos do Profast.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial. Em suas versões, os policiais narraram claramente atos de traficância.

Nada faz crer que os policiais estejam agindo imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura tendentes a elucubrar versão incriminadora para aprisionar injustamente pessoas com as quais não mantêm qualquer relação de desafeto comprovada.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmago psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não

provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

As defesas preliminares ou memoriais finais não se fizeram acompanhar de quaisquer imagens sobre o local do crime a fim de que pudesse ser demonstrado ao Juízo realidade diversa daquela que vem descrita pelos policiais empenhados na diligência.

Absolutamente afastada a hipótese de flagrante forjado, pois o réu Reinaldo confessa a propriedade das drogas ali apreendidas.

A partir deste ponto inicial, ou seja, de que um dos flagrados era proprietário das drogas, no caso Reinaldo, assume clara robustez a prova acusatória.

Com efeito, Reinaldo é exatamente aquele que foi identificado pela polícia como sendo o responsável por entregar as drogas para os corréus que "serviam" os usuários que se aproximavam da "biqueira" como é de praxe no método de traficância desenvolvido naquele ponto. Sendo Reinaldo o dono confesso das drogas, coerente que ele as tivesse guardadas nas imediações da escada, facilitando o acesso e abastecimento e João Paulo e Thiago.

A versão dos réus de que teriam apenas ingerido bebida alcoólica junto a Reinaldo, pessoa que desconhecem, soa inverossímil. Como apontou o Ministério Público "causa estranheza alguém dar bebida a pessoa que não conhece" (pgs. 531).

No que tange à alegação defensiva de nulidade da busca domiciliar e invalidade das provas decorrentes da diligência, tem-se que a narrativa fática apresentada pelos policiais não indica ingresso em qualquer residência, mencionando apenas uma escada que ficaria do lado de fora dos predinhos do "Profast". Como registrado acima, a defesa não apresentou imagens do local a fim de que o Juízo pudesse aquilatar se o ponto da apreensão de fato pode colmatar-se ao conceito normativo de "domicílio" e suas extensões.

Relembre-se de que o ônus da alegação incumbe a quem a fizer, na exata dicção do art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, não ocorre inversão ao ônus da prova atentatória à presunção de inocência, incumbindo à defesa apresentar provas sobre a realidade que tenta fazer prevalecer em juízo.

Não bastasse tal questão, cabe consignar que este Juízo tem acompanhado com a devida atenção as vicissitudes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de hipóteses em que têm sido considerada ilegal a busca e apreensão sem a prévia expedição de mandado judicial.

Neste esforço, percebe-se que não há consenso da Corte Superior, verificando-se que a Quinta Turma vem procurando preservar a jurisprudência há muito sedimentada a respeito das consequências inerentes ao estado de flagrante decorrente de crime permanente, dentre as quais viabilizar o ingresso domiciliar sem a necessidade do mandado de busca e apreensão.

Observe-se o precedente recentíssimo, publicado na última sexta-feira - 16 de dezembro de 2022:

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.

POLÍCIA MILITAR. USURPAÇÃO DE COMPETENCIA. NÃO CARACTERIZADA. ATO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. MUDANÇA DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM DA PENA SUPERIOR AO PERMITIDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de ser "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). III - No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a legalidade da incursão no domicílio no fato dos policiais estarem averiguando denúncias de tráfico de drogas, supostamente exercido pelo agravante, tendo surpreendido o mesmo na posse de drogas, quando da abordagem em via pública, oportunidade em que foi preso em flagrante e, em busca domiciliar, com entrada franqueada pela companheira do agravante, foram encontradas mais drogas, bem como a arma com numeração suprimida, sem comprovação de origem lícita. IV - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - As instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o agravante praticou os crimes a ele imputados. Assim, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - No tocante à diligência policial, como bem ponderou o Tribunal de origem, "Não houve investigação, mas sim repressão imediata, o que se inclui no exercício da polícia ostensiva e preventiva das polícias militares, nos termos do artigo 144, §5º da Constituição Federal. Vale dizer, a prisão em flagrante do acusado não usurpou a atribuição investigatória da Polícia Civil, tanto que apresentado no Distrito Policial para início da investigação" (fls. 223-224), a polícia agiu na imediata comunicação dos fatos, indo averiguar, em ato típico de polícia ostensiva. Não caracterizada usurpação de competência. VII - Não havendo desclassificação, bem como tendo que as penas estão no seu mínimo legal, não cabe a mudança de regime, uma vez que acima de 4 anos, o que vai ao encontro à disposição legal da alínea b, do § 2º, do art. 33, do Código Penal. VIII - Não há como promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que supera o quantum de pena permitido pelo comando legal do inciso I, do caput, do art. 44, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 745.414; Proc. 2022/0162407-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/12/2022; DJe 16/12/2022

Em outra decisão recente, publicada no dia 13 de dezembro de 2022, a legalidade da diligência foi reconhecida em circunstância fática similar a do presente caso. Réu abordado em via pública, em conhecida "biqueira", o que foi suficiente para autorizar o posterior ingresso domiciliar (que no presente caso sequer é certo que tenha ocorrido):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE ABORDADO NA VIA PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA

RESIDÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o réu foi abordado ainda em via pública, em conhecido local de traficância, no momento em que trazia consigo certa quantidade de droga, o que justificou o posterior ingresso dos policiais em sua residência, pois restou devidamente configurada a situação de flagrância. Nesse contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que o acusado exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, estando, pois, devidamente justificada a entrada dos milicianos no interior do seu imóvel. 2. "A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi observado no caso em análise." (AGRG no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 3. A suscitada ilegalidade da busca pessoal não foi aventada nas razões do Recurso Especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.176.309; Proc. 2022/0231703-5; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022 (destaques do Juízo)). Conclui-se, sem maior esforço, que a prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes que alicerçam a presente ação penal estão em perfeita harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima ilustrada.

De rigor, portanto, o afastamento de qualquer mácula, nulidade ou irregularidade na atuação policial que em estrito cumprimento do dever legal não trouxe nenhum vício a actio poenale.

No que tange à alegada drogadição formulada especialmente pelo réu João Cláudio dos Santos Silva é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DO DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 116/118, para CONDENAR JOÃO CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA e THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e REINALDO CORTEZ RUFINO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, todos ajustados na forma do art. 29 do Código Penal, passando a dosar-lhes as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Primeiramente em relação ao réu Reinaldo Cortez Rufino, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 38,66 gramas, conforme págs. 253/261.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando estes itens o Juízo encontra campo para necessário acréscimo, pois a quantidade-variedade de drogas diferentes (no caso três - cocaína, crack e maconha) impõe aumento de pena, uma vez que o traficante que tem consigo uma variedade de tóxicos está pronto a atender parcela de usuários mais ampla, alcançando "maior clientela" e demonstrando nível superior de periculosidade do que aquele que fornece apenas uma espécie de droga. Assim, deve receber a reprimenda diferenciada em estrita observância ao mandamento constitucional de individualização da pena.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por força da diversidade de entorpecentes estabelecendo-a em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Reinaldo foi condenado definitivamente nos autos dos processos » Foro de São José do Rio Pardo - 2ª vara. Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: 0001346-03.2006.8.26.0575. Transito em julgado para a defesa aos 02.03.2007 - pg. 79 e » Foro de São José do Rio Pardo - 1ª vara. Ação Penal. Procedimento Ordinário: 0006174-37.2009.8.26.0575. Trânsito em julgado para a defesa aos 27.05.2014 - pg. 81.

Assim, por força dos maus antecedentes, novo acréscimo de 1/6 se impõe. Cabe salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive fazendo alusão ao entendimento do STF sobre a questão, é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64,

inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não obstam a configuração de maus antecedentes. Observe-se: "Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, como ocorrido na hipótese. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020). STJ; AgRg-HC 775.863; Proc. 2022/0317744-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022 (destaque do Juízo) "

Com efeito, a pena na primeira fase recebe acréscimo de 1/6 pela quantidade-variedade de drogas e 1/6 pelos maus antecedentes, chegando ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

No entanto, Reinaldo é confesso e deve ser beneficiado a teor do disposto na súmula 545 do E. STJ. Atenuo a pena em 1/6, mantendo-a no patamar de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena supra.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter equiparado a hediondo da conduta. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Como razão adicional, impõe-se considerar que apenas o regime fechado é capaz de desfazer a "teia" criminosa na qual o réu estava envolvido, pois regimes que permitem contato com o meio aberto viabilizam que o réu continue tendo acesso a fornecedores de maior envergadura, bem como sua "clientela".

Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao seu perfil.

Permito que recorra em liberdade, diante da decisão de pgs. 313/314 que revogou sua custódia cautelar.

A pena de João Cláudio fica assim fixada:

Na primeira etapa fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por força da diversidade (1/6) de entorpecentes estabelecendo-a em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

A respeito da anotação contida nas pgs. 85, observa-se que foi aceito e cumprido o benefício da transação penal, de modo que não contém tal anotação densidade criminológica suficiente para agravar a pena do réu ou obstar-lhe o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentação infra.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para

indicar ligação a organização criminosa.

Portanto, considerando que o réu é primário e a apreensão não possui dimensão suficiente para indicar que o réu integra organização criminosa deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo.

Deste modo, reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 194 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 01 ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 194 dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

Evidentemente que as instâncias ordinárias deverão observar se o entendimento se firmará e quais serão seus demais contornos e reflexos. Ressalvo, ainda, meu posicionamento pessoal sobre a maior adequação do regime inicial fechado para os casos de tráfico de entorpecente, que se sustentava, entretanto, também em sua equiparação a crime hediondo.

Em matéria disponível no site "Conjur", divulgada em 2016, verifica-se que novamente o E. STF entendeu pela impossibilidade de fixação do regime fechado aos casos de tráfico privilegiado. As decisões são do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli e foram proferidas em dois pedidos de HC impetrados pelo defensor público Alexandre Orsi Netto, que atua em Sorocaba.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

No Habeas Corpus nº 457.359/SP (2018/0162657-9), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.08.2018 o E. STJ reafirmou a mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do Enunciado nº 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime, ou ainda o teor da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal.

Eis o teor das súmulas citadas:

SÚMULA Nº 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

SÚMULA Nº 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

SÚMULA Nº 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com tais fundamentos, fixo o regime ABERTO, considerando os